

1502954-28.2019.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Desconhece se Matheus trabalha para o tráfico de drogas. O interrogando afirma que não trabalha no tráfico de drogas e somente é usuário de drogas (fl. 05). Em juízo, negou a veracidade dos fatos apresentados. Disse que foi buscar pinos de crack para consumo próprio. Era usuário na época. Estava saindo do ponto de tráfico e encontrou-se com Matheus e este lhe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502954-28.2019.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502954-28.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2321914/2019 - 09º D.P. GUARULHOS, 8384637 - 09º D.P. GUARULHOS, 2716/19/221 - 09º

D.P. GUARULHOS, 2321914 - 09º D.P. GUARULHOS, 2716/19/221 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FURTADO LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

MATHEUS FURTADO LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 333, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal e LUCIANO FERNANDES ANDRADE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Segundo a denúncia, no dia 5 de novembro de 2019, por volta das 7h20min, na Avenida Palmira Rossi, nº 1.700, Cabuçu, nesta cidade e comarca de Guarulhos, MATHEUS FURTADO LIMA e LUCIANO FERNANDES ANDRADE DOS SANTOS, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios, traziam consigo, para entrega à consumo de terceiros, 1,25g (um grama e vinte e cinco centigramas) de cocaína na forma de crack distribuídos em 6 invólucros, droga ilícita que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme boletim de ocorrência a fls. 7/12, auto de exibição e apreensão a fls.

13/14 e laudo de constatação a fls. 16/18).

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MATHEUS FURTADO LIMA ofereceu e prometeu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício (fls. 72/74).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/67).

Em 06 de novembro de 2019, na audiência de custódia do Foro Plantão - 44ª CJ - Guarulhos, foi relaxada a prisão em flagrante dos acusados Matheus e Luciano (fls. 48/50).

Devidamente notificado (réu Matheus - fls. 86/87), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (réu Matheus - fls. 106/107). O corréu Luciano foi notificado por edital (fl. 99, fl. 102 e fl. 109).

Em 12 de abril de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia com relação ao acusado Matheus. Na oportunidade, considerando que foi tentada a localização do acusado Luciano em todos os endereços que constam dos autos e, citado por edital, não respondeu ao chamamento judicial, nos termos do artigo 366 do C.P.P., foi suspenso o curso do processo, bem como o prazo prescricional (fl. 120/123).

Restou prejudicada a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 22 de julho de 2021, face à ausência das testemunhas (fls. 159/160).

Diante da notícia nos autos da prisão em flagrante delito do corréu Luciano por outro feito (fls. 161/170), procedeu-se a notificação do referido acusado (fls. 178/179).

Em 05 de novembro de 2021, considerando que o acusado Luciano foi devidamente notificado, nos termos do artigo 366 do C.P.P., com a redação dada pela Lei n.º 9271/96, foi revogada a suspensão do feito e os autos retomaram a marcha processual normal (fl. 188).

A Defensoria Pública ofereceu resposta à acusação referente ao acusado Luciano, com rol de testemunhas comuns em audiência, oportunidade em que também foi mantido o recebimento da denúncia em relação ao corréu Luciano (fl. 203).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, ocorrida em 11 de novembro de 2021, foram colhidos os depoimentos das duas testemunhas comuns. Em seguida, os réus MATHEUS e LUCIANO foram interrogados (fls. 202/209). Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação dos acusados. A respeito do cálculo de pena, a pena-base poderá ser fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza das drogas localizadas com os réus. Outrossim, Luciano ostenta maus antecedentes, inclusive, pela prática de tráfico. Ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inviável o reconhecimento do art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06. Quanto à Matheus, deve ainda incidir a causa de aumento de pena relativa ao concurso material de crimes. O regime deverá ser o fechado. Em virtude da pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP. A prisão dos réus deve ser mantida, diante da comprovada inserção na seara criminosa do tráfico. Requereu, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 203/205).

A defesa de LUCIANO e MATHEUS, por sua vez, não havendo provas contundentes e seguras para embasar decreto condenatório em desfavor dos réus, requereu as absolvições por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Diante do quadro probatório que se apresenta, postulou a desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou: a fixação das penas-base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima; a fixação de regime inicial aberto; a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Requereu por fim, seja conferido aos réus o direito de recorrerem em liberdade, bem como a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (fls. 205/209).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente

O acusado MATHEUS FURTADO LIMA, em sede policial, esclareceu que estava conduzindo sua motocicleta marca Yamaha/fazer, de cor preta, não se recordando a placa. Encontrou-se com Luciano, conhecido seu há mais de dois anos, o qual lhe pediu uma carona, e de pronto o interrogando lhe deu. Quando estavam indo até a casa de Luciano uma viatura da polícia militar, deu sinal de parada ao interrogando. Como o interrogando não é habilitado e Matheus estava sem capacete, temendo que sua moto fosse apreendida, o interrogando empreendeu fuga, sendo perseguido pela viatura. Em dado momento o interrogando perdeu o controle da moto e sofreu uma queda, sendo então alcançado pelos policiais militares. Nada de ilícito foi encontrado com o interrogando ou com Matheus. O interrogando carregava em seu bolso a quantia de R\$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), de sua propriedade. O interrogando esclarece que os policiais que lhe perguntaram se ele tinha mais dinheiro e o interrogando perguntou aos policiais que se ele arrumasse mais dinheiro poderia ir embora. O interrogando nega que tenha oferecido dinheiro aos policiais para poder ir embora (fls. 06). Em juízo, disse que estava com a droga, para consumo pessoal, mas não ofereceu nada aos policiais. Os policiais que perguntaram se ele teria algo para dar para eles. Relatou que com ele foram encontrados seis pinos de crack. Afirmou já ter sido usuário de crack, por cerca de dois anos e, naquela época, em 2019, recaiu. No momento da abordagem estava indo "buscar" drogas. Depois de comprar, estava saindo do local e encontrou o corréu Luciano, que pegou uma carona. Acrescentou que, saindo do ponto de entorpecentes, encontraram com uma viatura, que deu sinal para pararem, mas Luciano não obedeceu. Isso ocorreu, pois estava com os documentos da moto atrasados, sem a habilitação e sem capacete. Acelerou, caíram de moto, e os policiais os detiveram. Disse que o traficante correu e Luciano viu, pois havia comprado com ele. O interrogando pegou depois. Quando chegou, Luciano já estava saindo do ponto. Confirmou que compraram drogas do mesmo traficante. Comprou do mesmo indivíduo que Luciano acabara de comprar. Após fugir, encontraram as drogas com o interrogando. Reiterou que os policiais perguntaram sobre algum dinheiro, chegaram a mencionar a moto em que estava, dizendo-lhes que poderia ver. Recordou que tal negociação não se seguiu, pois chegaram mais duas viaturas no local, então, acabou a negociação. Negou que conhecesse os policiais. Acredita que os policiais deram tal versão, pois estava saindo de um ponto de drogas, com dinheiro no bolso, além do fato de encontrarem entorpecentes em seu poder. Os policiais pensaram que era encarregado de alguma função dali, mas não era. Não soube dizer os motivos para os policiais inventarem tal situação.

O acusado LUCIANO FERNANDES ANDRADE DOS SANTOS, em sede policial, esclarece que conhece a pessoa de Matheus há cerca de dois meses. O interrogando esclarece que retornava de uma biqueira onde havia ido comprar um pino de cocaína, pois é usuário de drogas desde seus 16 (dezesesseis) anos. Quando voltava para casa encontrou com Matheus, o qual estava de moto e ofereceu carona ao interrogando. Foram então abordados por policiais militares, sendo que a moto já estava rodando e o interrogando na garupa. Nada de ilícito foi encontrado com o interrogando, porém com Matheus os policiais localizaram droga e dinheiro. Desconhece se Matheus trabalha para o tráfico de drogas. O interrogando afirma que não trabalha no tráfico de drogas e somente é usuário de drogas (fl. 05). Em juízo, negou a veracidade dos fatos apresentados. Disse que foi buscar pinos de crack para consumo próprio. Era usuário na época. Estava saindo do ponto de tráfico e encontrou-se com Matheus e este lhe perguntou se queria uma carona, pois mora ali próximo e estava de moto. Aceitou a carona. Relatou que, quando saíam da viela, depararam-se com uma viatura vindo, de modo que tentaram evadir, pois o interrogando estava sem capacete e Matheus sem a habilitação. Caíram, pulou da garupa, pois já estava sob o efeito de drogas. Não encontraram nada com o interrogando, pois acredita que perdeu o pino que havia comprado. Comprou crack na data dos fatos, mas não soube dizer o nome do vendedor, pois eles não divulgam e ficam mais escondidos para os usuários de crack. Simplesmente pegou da mão do vendedor e ia saindo. Esclareceu que, quando comprou a droga, os policiais militares ainda não haviam aparecido, pois é "um pouco mais para dentro" o ponto do tráfico. Foi quando eles estavam saindo de moto, fizeram a

curva à direita, onde tinha um caminhão baú, que os policiais saíram de trás deste caminhão. Negou que, naquele momento, tenha existido um terceiro indivíduo que correu após passar algo para os réus. Disse não saber o que Matheus fazia pelo local, mas ele residia ali próximo. Acredita que ele também estava buscando drogas para uso. Não soube dizer se algo foi encontrado com Matheus, pois os policiais os afastaram, cada um foi para um lado diferente. Não se recordou do depoimento dado em solo policial, onde disse que com Matheus foram encontrados entorpecentes. Afirmou conhecer Matheus da vizinhança, há aproximadamente dois anos, pois cresceu por ali. Não soube dizer se Matheus realmente ofereceu dinheiro e drogas aos policiais, pelo fato de terem sido separados. Negou, por fim, estar traficando ou colaborando com o tráfico.

Os policiais militares ALESSANDRO ARAUJO DE SOUSA e ROBERTO PEREIRA CAVALCANTI AGUIAR, em sede inquisitorial, em depoimentos semelhantes, narraram que estavam em suas atividades na circunscrição do Distrito Policial, notadamente na Rua Paqueta, com a viela Santos, onde existem inúmeras reclamações relativas ao tráfico de drogas. Desta forma, visavam coibir o comércio ilegal de drogas, quando viram duas pessoas em uma motocicleta, o qual o condutor MATHEUS FURTADO LIMA pegou algo com uma terceira pessoa, sendo que esta conseguiu empreender fuga, sendo que ao avistarem a viatura demonstraram nervosismo e incontinentemente aceleraram a motocicleta na tentativa de ludibriar a abordagem. Com isso iniciou-se uma breve perseguição onde somente cessou na Av. Palmira Rossi, altura do numeral 1700, devido ao condutor perder a direção e vir ao solo, mesmo assim o garupa LUCIANO FERNANDES ANDRADE DOS SANTOS levantou-se e tentou homiziar-se, sendo capturado na sequência pelo Policial Militar. Foram procedidas buscas pessoais em MATHEUS FURTADO LIMA onde localizou-se a importância de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) mais 06 (seis) epeendorfs de crack, em seu bolso e na sua carteira os policiais encontraram mais R\$ 5,00 (cinco reais), enquanto em poder de LUCIANO, nada de ilícito foi encontrado. Após os procedimentos padrões realizados pelos ostensivos MATHEUS FURTADO LIMA ofereceu a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mais aproximadamente 05 (cinco) quilos de maconha, que estaria enterrada dentro de uma comunidade aos Policiais para que ele e seu parceiro LUCIANO não fossem presos (fls. 03/04).

Em juízo, o policial militar ALESSANDRO ARAUJO DE SOUSA recordou-se, salvo engano, do indivíduo de crachá nº 1 (Luciano), de uma ocorrência de tráfico de entorpecentes. Narrou que estavam em patrulhamento, na região do Recreio São Jorge, e visualizaram dois indivíduos em uma moto recebendo algo de um terceiro. Esclareceu que o local era conhecido como ponto de tráfico - uma travessa da Rua Paqueta, na viela Santos. Foi nesta esquina que se depararam com os três: Dois em uma motocicleta e um a pé. Disse que, quando visualizaram a viatura, o que estava a pé correu para um matagal da região, enquanto os outros dois tentaram fugir de moto. Explicou que fizeram um breve acompanhamento, pelas ruas do Recreio São Jorge, até que o motorista perdeu o controle da moto e caiu. O garupa, Luciano, saiu correndo e se escondeu em um terreno, mas foi abordado. Contou que seu parceiro deteve Matheus, e o ficou esperando voltar com Luciano. Afirmou que, depois de voltar com Luciano, realizaram a busca pessoal nos réus. Matheus, que conduzia a moto, possuía R\$275,00 reais e cinco pinos de crack. Questionado ele disse não ser usuário e que realizava o "recolhe" na região. Acrescentou que o réu ofereceu, em uma conversa informal, dinheiro e drogas aos policiais para não ser preso. Relatou que não havia nada com o outro indivíduo. Esclareceu que Matheus era o indivíduo que passava nos lugares de venda de droga e recolhia dinheiro e a droga que sobrou. Esclareceu, ainda, que ele não disse com quem trabalhava, mas afirmou que entraria em contato com alguém para disponibilizar o dinheiro e as drogas, se os policiais quisessem - se tratava de cerca de R\$5.000,00 e quilos de maconha, enterrados na região, e ele era o responsável. Negou que tenha sido encontrado algo com o réu Luciano, que mais parecia um usuário de drogas ou alguém que vendia drogas, pois muitos usuários também vendem. Contou que o réu Luciano alegou estar pegando uma carona com o amigo e, ao ser questionado sobre o "recolhe" citado por Matheus, disse que não sabia informar. Matheus, que confessou estar no "recolhe" de drogas, disse que Luciano trabalhava para ele, vendendo drogas no local. Negou que

conhecesse os réus. Acrescentou que o réu Matheus residia próximo à viela Santos, fugiu por várias ruas na ocasião e o alcançaram longe de sua casa. Confirmou que todos os policiais com quem trabalha conhecem o local dos fatos como um ponto de tráfico de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar e ROBERTO PEREIRA CAVALCANTI AGUIAR, o qual, em juízo, recordou-se dos réus. Narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento e visualizaram três indivíduos em local conhecido como ponto de tráfico. Eles perceberam a presença da viatura e se evadiram em uma moto preta. Depois de breve acompanhamento, a moto caiu. Um indivíduo correu e outro ficou, de modo que seu parceiro correu e alcançou o primeiro rapaz. Disse que, pressionado, o indivíduo de crachá nº 2 (Matheus), falou que fazia o "recolhe" nos pontos de tráfico. Ele estava com uma quantidade de drogas e dinheiro e foi deslocado até uma UBS, devido às escoriações e, após, ao 9º D.P. Recordou que, quando os visualizaram na viela, os dois indivíduos já estavam embarcados na moto e um terceiro indivíduo, que estava a pé, correu. Contou que era como se estivessem fazendo uma movimentação, algum tipo de entrega, mas não conseguiram visualizar o que era. Afirmou que, posteriormente, Matheus (crachá nº 2), confessou estar ali para fazer o "recolhe" nos pontos de tráfico. Ele era o condutor da moto. Recordou-se que Matheus foi quem ficou no local, de modo que o outro indivíduo correu. Confirmou que foram apreendidos "pinos" e dinheiro no bolso de Matheus. Pelo que se recorda, tratava-se de seis pinos de cocaína, quantidade pouca e R\$200,00. Disse que, inclusive, Matheus chegou a oferecer drogas e dinheiro à equipe para não ser preso. Não se recordou sobre se alguma quantia foi mencionada. Negou que algo tenha sido encontrado com o indivíduo de crachá nº 1 (Luciano), que argumentou ter pegou uma carona com o corréu. Não o questionaram sobre o "recolhe" mencionado pelo outro indivíduo. Negou que já conhecesse os réus. Negou, também, que o réu Matheus tenha dito de onde eram as drogas ou dinheiro que lhes entregaria, pois não ficaram estendendo este assunto. Esclareceu que esta oferta foi feita aos dois policiais, à equipe. Ressaltou que a viela citada é conhecida como ponto de tráfico por quem trabalha na área, inclusive outras pessoas já foram presas ali. Questionado pela defesa sobre uma possível campana ou se já chegaram e abordaram os indivíduos, respondeu que não, pois tratava-se de um patrulhamento normal, de rotina, por voltas das oito horas da noite. Questionado se outras drogas, além da cocaína, foram encontradas com Matheus, respondeu que, pelo que se recorda, apenas cocaína foi encontrada, cerca de seis pinos. Questionado sobre o terceiro indivíduo, respondeu que ele correu e se evadiu para mata, pois é uma viela com áreas de mata nas laterais. Questionado, ainda, sobre a presença de outras pessoas nas proximidades, respondeu que, pelo que se recorda, havia somente os três indivíduos. Às vezes, passam transeuntes pelo local naquele horário.

Pois bem, no que tange ao crime de tráfico de drogas imputado aos acusados, respeitado entendimento diverso, a hipótese é de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06 para o réu Matheus e de absolvição para o réu Luciano, senão vejamos.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/12), auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória de entorpecentes (fls. 16/18), exame químico-toxicológico (fls. 155/156), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA, bem como pela prova oral trazida aos autos.

Também é inconteste que a droga apreendida (6 invólucros de cocaína na forma de crack) estava em poder do acusado Matheus, diante da confissão judicial do próprio réu e dos depoimentos dos policiais apresentados em juízo, os quais afirmaram que o entorpecente foi apreendido com o citado acusado, sendo que também atestaram que nada foi localizado em poder do denunciado Luciano.

Os réus Matheus e Luciano, por sua vez, em juízo, negaram veementemente o envolvimento na traficância, declarando judicialmente que estavam no local para comprar droga para consumo pessoal.

A discussão, portanto, restringe-se ao destino do entorpecente apreendido com o acusado Matheus e eventual colaboração do corréu Luciano, sendo que neste ponto,

forçoso reconhecer que não há no presente feito provas seguras da traficância. Isto porque, conforme noticiado pelos policiais os réus foram vistos em uma moto, em local conhecido como ponto de venda de droga, aparentemente pegando algo de um terceiro rapaz que estava no local e fugiu a pé. Pela conduta relatada pelos policiais, os réus tanto poderiam estar realizando o recolhimento da droga como poderiam estar adquirindo entorpecente para o uso.

Nos autos, a apontar o destino da droga para o comércio a terceiros há apenas a confissão informal do acusado Matheus noticiada pelos policiais, bem como suposta delação também informal de Matheus, alegando que Luciano trabalhava para ele, conforme depoimento judicial do policial militar Alessandro.

Nesse ponto, embora não se negue credibilidade aos depoimentos dos policiais, nem se coloque em dúvida a lisura da diligência que resultou na apreensão da droga e o fato de Matheus ter confessado informalmente a traficância, certo é que se nem mesmo uma confissão formal do acusado pode servir como único elemento de prova a fundamentar um decreto condenatório, com menor razão pode um decreto condenatório se basear em mera confissão ou delação informal.

Ademais, a quantidade de droga apreendida (1,25g), por sua vez, não era extraordinária a ponto de justificar a presunção de que se destinava ao comércio clandestino, mas pelo contrário, é compatível com a posse para uso, além do que não foi presenciada nenhuma atividade de mercancia pelos policiais militares.

Noutro giro, é verídico que, depois da prisão em flagrante no presente feito, o acusado Matheus foi preso por tráfico de drogas, fato pelo qual já foi condenado, além do acusado Luciano ter duas condenações anteriores por tráfico e, após os fatos, também ter sido preso mais uma vez pelo mesmo delito, circunstâncias que apontam para o envolvimento de ambos com a atividade de comércio de drogas e permitem desconfiar que as drogas com eles apreendidas realmente estavam relacionadas ao tráfico e não ao consumo próprio.

No entanto, o direito penal não se coaduna com meras suposições, havendo necessidade de um juízo de certeza, o qual não foi alcançado nos autos, até porque é comum usuários trabalharem no tráfico para garantir o vício e, no caso em concreto, pela pouca quantidade de droga apreendida, não é possível saber se os acusados, supostamente usuários, na ocasião da abordagem, estavam comprando entorpecente para uso ou trabalhando no tráfico.

Por outro lado, como já explicitado acima, restou incontroverso que o acusado Matheus trazia consigo seis invólucros de cocaína na forma de crack, porções estas que pela quantidade, natureza e demais circunstâncias da prisão, devem ser consideradas para seu uso e não para o tráfico.

Assim, a meu ver, a ilação da mercancia, nas circunstâncias dos autos, é tímida e, pela prova colhida, não se tem comprovado o dolo de mercador exigido pelo tipo penal incriminador descrito na peça vestibular, o que impõe a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 para o acusado Matheus.

Nesse sentido: "Apelação Criminal n.º 265.405-3, Campinas, 3ª Câmara Criminal de Férias de Janeiro de 1999, Relator Desembargador OLIVEIRA RIBEIRO. No mesmo sentido, colhe-se: "Dúvida quanto à atividade de mercancia da acusada ou de que guardava a droga - Fato que autoriza a desclassificação - Recurso provido" (Apelação Criminal n.º 219.548-3, São Paulo, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. DANTE BUSANA).

Nunca é demais lembrar que para o reconhecimento do tráfico ou comércio de drogas, mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se a droga apreendida com o réu era destinada ao tráfico ou ao uso, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do princípio do in dubio pro reo. A propósito: "A apreensão de apreciável quantidade de tóxico, por si só, não basta ao reconhecimento da traficância" (Rev. Tribs., vol. 608, p. 323; rei. Gonçalves Sobrinho).

Na mesma linha também já decidiu o E. TJSP: "Inexistindo prova segura de que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao comércio ilícito, e restando demonstrada, pela prova oral colhida, pela pequena quantidade de drogas apreendidas e pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que as drogas seriam para consumo próprio, imperiosa a manutenção da desclassificação de tráfico para

uso de drogas" (TJSP; Apelação 0053441-52.2014.8.26.0050; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2018; Data de Registro: 10/04/2018).

Oportuno acentuar que, do ponto de vista processual e legal, não há qualquer óbice para a admissibilidade da desclassificação do artigo pelo qual o réu foi denunciado para o artigo 28 da Lei de Tóxicos sem que se baixe o processo à defesa, não só porque significa uma solução mais benéfica para o réu, como também a falta de baixa dos autos não lhe constitui surpresa em prejuízo, até porque sendo o crime de tráfico um plus em relação ao simples uso, nada impede que o Juiz prefira enquadrar o réu na primeira fase dessa infração.

Nesse sentido RJTJSP 74/344.

A vista do exposto, e porque não se pode afirmar, com a necessária segurança o tráfico, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, dou novo enquadramento jurídico aos fatos, desclassificando a conduta do réu MATHEUS, do artigo 33, caput, para o artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Quanto ao acusado LUCIANO, como já delineado acima, restou demonstrado, no decorrer da instrução criminal, que não foi apreendido qualquer entorpecente em seu poder, embora tenha admitido que antes da abordagem policial adquiriu drogas para consumo. Além do mais, não há elementos que indiquem, de forma segura e clara, a participação e/ou colaboração do citado denunciado numa eventual finalidade mercantil dos entorpecentes, sendo absolutamente temerário condená-lo com indícios tão frágeis.

É sabido que, para a decretação de uma sentença condenatória, o juízo deve ter plena convicção a respeito da materialidade e autoria delitiva, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, ante da dúvida quanto à autoria delitiva, a absolvição do réu LUCIANO é medida de rigor, pois no processo penal, a dúvida deve beneficiar as Defesas aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência:

"Diante da fragilidade da prova de efetivo envolvimento do acusado no crime em questão, é o caso de incidência dos brocardos in dubio pro reo e favor rei somente restando proclamar a improcedência da pretensão ministerial" (STF, AP n. 678, Min. Dias Toffoli, j. 18.11.2014);

"Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática". Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136);

"Se o espírito do magistrado é animado pela incerteza, forçoso convir que outro caminho ele não terá, senão o da absolvição, pois é máxima de processo penal que a dúvida, sentimento alternativo que inclui o sim e o não, sempre deve prevalecer em benefício do réu" (TACRIM 11 C AP 10811421/2 J. 9.2.98 Rel Xavier de Aquino Rolo-flash 1.155/060);

"Prova - Elementos insuficientes para configuração do crime. Absolvição - Necessidade. A dúvida, quanto à configuração do crime por insuficiência probatória, deve ser resolvida em proveito do réu com a absolvição" (TACRIM 11 C. AP 787773 J. 22.8.94 Rel. Fernandes de Oliveira Rolo-flash 857/208).

No mesmo sentido, ensina Heleno Cláudio Fragoso:

"Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade"

(Fragoso, Heleno Cláudio. Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, p. 506).

Noutro vértice, deve ser reconhecida a prática do crime de corrupção ativa previsto no artigo 333 do Código Penal praticado pelo acusado MATHEUS.

Com efeito, o artigo 333 do Código Penal prevê a conduta de "Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício".

Quanto ao referido delito, é de se reconhecer que a prova é segura e suficiente para atestar a materialidade e autoria delitiva, pois, conforme narrado pelos policiais de forma uníssona, em ambas as fases da persecução penal, o acusado Matheus, a fim de evitar sua prisão e do seu amigo Luciano, e almejando serem liberados, ofereceu aos policiais o montante em dinheiro de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e mais aproximadamente 5kg de maconha, que estariam enterrados dentro de uma comunidade.

Nota-se que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, não tendo a Defesa produzido qualquer prova que fizesse este juízo acreditar que pudessem estar mentindo e acusando injustamente o réu, até porque, sequer o conheciam. Assim, suficientes para a certeza da prática delitiva tais depoimentos.

Logo, a prova é contundente para atestar a materialidade e autoria delitiva, pois restou demonstrado que o réu ofereceu vantagem indevida aos milicianos que o abordaram, com o intuito de que eles omitissem ato de ofício, qual seja, especificamente a obrigação legal de prendê-lo em flagrante, sendo de rigor a condenação pelo delito de corrupção ativa.

O delito previsto no artigo 28 "caput", da Lei n.º 11.343/06 e o crime de corrupção ativa (artigo 333, caput do Código Penal) são autônomos, razão pela qual as penas devem ser cumulativas, restando caracterizado o concurso material de crimes, conforme tipificado no artigo 69, caput, do Código Penal.

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a parcial condenação somente do acusado MATHEUS, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

I-) Réu MATHEUS FURTADO LIMA:

A) Do delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei n.º 11.343/2006:

Quanto ao delito tipificado no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, diante da primariedade e bons antecedentes do acusado, aplico a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Observo que a despeito da desclassificação operada, não faz jus o acusado aos benefícios da transação penal e suspensão condicional do processo, em razão de responder nestes autos por delito de corrupção, além de estar respondendo por outro delito de tráfico de drogas (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 150/151).

b) Do delito previsto no artigo 333, "caput" do Código Penal:

Na dosagem das penas, na primeira fase, temos que o réu é primário (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 150/151 e F.A. de fl. 143 e fls. 144/146) e cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal, podendo ter a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na derradeira etapa, não há causas de aumento e de diminuição de pena a serem

analisadas, razão pela qual torno as penas definitivas em 2 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Os crimes foram praticados em concurso material, portanto, suas penas devem ser somadas.

Diante da quantidade da pena fixada e o réu ser tecnicamente primário, fixo, desde já, regime ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Pelo mesmo fundamento, considerando a quantidade da pena aplicada e o fato do acusado ser tecnicamente primário, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, na proporção de uma hora de serviço por cada dia de pena, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (dez dias-multa, no menor patamar), pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base, sem prejuízo da pena de multa cominada no preceito secundário do tipo penal.

No mais, considerado que o réu Matheus responde o processo solto e levando em conta o regime fixado, bem como a aplicação de penas alternativas, reconheço seu direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

I - CONDENAR MATHEUS FURTADO LIMA, qualificado nos autos, incurso no artigo 333 do Código Penal, ao cumprimento de 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, substituído por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, na proporção de uma hora de serviço por cada dia de pena, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), além do pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal e também como incurso no artigo 28, "caput", da Lei n.º 11.343/06, ambos os crimes na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, a pena de advertência sob os efeitos da droga.

II - ABSOLVER LUCIANO FERNANDES ANDRADE DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação que lhe move a Justiça Pública, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O acusado Matheus poderá recorrer em liberdade.

Condeno o réu Matheus ao pagamento das custas processuais. Defiro aos acusados os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que os acusados têm condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu Matheus, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu Matheus.

P.I.C.

Guarulhos, 16 de fevereiro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA